

2023년 시행 변리사 2차시험 민사소송법 해제 및 평가

총 평

변호사시험 등 기타 시험에서 민사소송법을 강의하던 중, 23년 올해 3월 한빛변리사학원에서 민사소송법 강의를 첫 진행하여 8월에 이르기까지 특강 GS는 사실상 1회, 최근 판례·병합과 상소·기출문제 특강 등 총합 4회 정도의 강의를 진행한 바 있다.

여러분들의 빛나는 노력에 부응할 수 있도록, 시험이 얼마남지 않은 시점에서도 그 짧은 몇 안되는 특강들 속에서도 진주를 찾으려는 마음으로 신중할 수 밖에 없었다. 그에 의한 것인지, 감사하게도 우리가 진행했던 그 많은 노력이 몇 안되는 그 특강 속에 실제 출제 형태로 적중되는 모습들을 보며, 참으로 다행이라는 생각이 든다.

문제의 전체적인 총평은 문제 1·2·3·4(1) 까지 중에는 미리 GS 등을 통하여 써보지 않고는 쉽게 답안구성을 하기 까다로움 부분과 기초적인 부분들이 혼재되어 있었고, 올해 문제의 사실상 키워드는 추후보완항소에서의 불귀책사유와 관련된 문제였다.

【문제 1】

甲은 乙에 대하여 구상금채권을 가지고 있는 채권자이다. 甲과 丙 사이에 甲이 乙에 대하여 가지고 있는 구상금채권을 양도·양수하는 계약을 체결하였다. 乙은 자신의 유일한 재산인 X부동산을 丁에게 매도하는 계약을 체결하였다. (다음 각 물음은 독립적임)

(1) 甲이 乙에 대하여 구상금청구의 소를 제기한 후 제1심 소송계속 중 丙은 甲으로부터 구상금채권을 양수하였음을 이유로 권리승계를 주장하면서 승계참가를 신청하였다. 甲은 丙의 승계 여부에 대하여 다투지 않으면서도 소송탈퇴, 소취하 등을 하지 않았다. 제1심법원은 丙이 甲으로부터 구상금채권을 양수한 채권자임을 전제로 丙의 청구에 대하여 판단하였고, 甲의 청구에 대하여는 판단하지 않았다. 이에 대하여 甲이 항소를 제기하였는데, 항소심법원은 불복의 대상이 되는 재판이 없어 항소가 부적법하다고 판단하여 甲의 항소를 각하하였다. 이와 같은 항소심법원의 판단에 잘못이 없는지를 그 논거와 함께 설명하시오. (10점)

4월 민 일 민소법 GS 문제 중 2023년 적중 출제

【문제 - 1】 - (1) 승계참가 이후 탈퇴하지 않은 당사자와 참가자 간의 소송관계

乙은 2023. 2. 5. 자신의 X토지에 관하여 계약금 2천만 원, 잔금 2억 원을 대금으로 하여 丙에게 매도하기로 매매계약을 체결하였고, 계약금은 당일 丙으로부터 지급받고, 잔금은 2023. 3. 5. X토지에 관한 등기서류를 교부받음과 함께 지급하기로 하였다. (아래 각 설문은 독립적임)

1. 乙은 2023. 3. 5. 약속한 법무사사무실에 X토지에 관한 일체의 소요 등기서류를 맡기었으나, 丙은 동일 나타나지 않고 매매대금을 지급하지 않았다. 이에 乙은 丙을 상대로 위 매매대금 2억 원의 지급을 구하는 소(‘이 사건 소송’)를 제기하였다. 아래 각 물음에 답하시오. (각 설문은 독립적임)

(1) 乙의 丙에 대한 2억 원의 매매대금지급을 구하는 소송의 제1심 계속 중 甲은 乙의 甲에 대한 위 매매대금지급청구권 전부에 관하여 채권압류 및 전부명령을 신청하여 법원으로부터 결정을 받은 후 丙에 대하여 위 전부금의 지급을 구하며 제1심 법원에 승계참가 하였다.

乙은 丙의 승계사실 여부에 대하여 다투지 않았고, 소송탈퇴를 구하였으나, 丙이 이를 동의하지 않자 자신의 丙에 대한 위 소를 취하지 않고 계속 하였다.

승계참가 이후 乙은 제1심 소송 계속 중 심리의 대상 중 하나로 乙의 丙에 대한 매매대금채권이 존재한 사실이 있는지를 심리하면서, 乙은 자신의 매매대금채권의 존재를 증명할 수 있는 증거를 제출한 반면 甲은 변론기일에 출석하지는 하였지만 최초 乙의 丙에 대한 매매대금채권의 발생사실에 대한 증명을 하지 않은 상태이다. 이 경우, 乙의 증명의 효력이 甲에게 미치는가. (10점)

(2) 丙이 乙에 대하여 양수금 청구의 소를 제기하면서 甲과 丙 사이에 체결한 양도양수계약서 사본을 증거로 제출하였다. 이에 대하여 乙이 부지로 다투었는데, 법원은 변론 전체의 취지에 의하여 원본의 존재와 진정성립을 인정하였다. 이와 같은 법원의 조치에는 위법이 없는지를 그 논거와 함께 설명하시오. (10점)

서증의 사본을 증거로 제출한 경우, 상대방이 부지로 다투고 있음에도 변론전체의 취지로 진정성립을 인정한 원심을 파기한 대법원 1996.3.8. 선고 95다48667 판결의 사안 내용을 그대로 출제한 것으로, 수험생들이 충분히 쉽게 풀 수 있는 기본 사항이었다.

민일 민사소송법 427면.

(3) 丙이 丁을 상대로 양수금채권을 피보전채권으로 하여 乙과 丁 사이의 위 매매계약의 취소와 가액배상을 구하는 채권자취소의 소를 제기하여 그 소장부분이 2022.9.5. 丁에게 송달

되었다. 丙은 또 이 사건 소송계속 중 丁을 상대로 乙에 대하여 가지고 있던 공사대금채권을 피보전채권으로 하여 위 매매계약의 취소와 가액배상을 구하는 채권자취소의 소를 제기하여 그 소장부분이 2022.9.12. 丁에게 송달되었다. 이와 같은 경우 법원은 어떠한 판단을 하여야 하는지를 그 논거와 함께 설명하시오. (10점)

아래 대법원 2012.7.5. 선고 2010다80503 판결을 출제한 것으로 1차 민법 공부할 때에도 학습하였을 기초적인 문제수준이다.

「채권자가 사해행위취소 및 원상회복청구를 하면서 보전하고자 하는 채권을 추가하거나 교환하는 것은 사해행위취소권과 원상회복청구권을 이유 있게 하는 공격방법에 관한 주장을 변경하는 것일 뿐이지 소송물 또는 청구 자체를 변경하는 것이 아니므로, 채권자가 보전하고자 하는 채권을 달리하여 동일한 법률행위의 취소 및 원상회복을 구하는 채권자취소의 소를 이중으로 제기하는 경우 전소와 후소는 소송물이 동일하다고 보아야 하고, 이는 전소나 후소 중 어느 하나가 승계참가신청에 의하여 이루어진 경우에도 마찬가지이다.(대법원 2012. 7. 5. 선고 2010다80503 판결)」

【문제 - 2】 (20점)

甲중중은 乙의 불법행위로 甲중중 소유의 X토지에 관한 甲중중의 사용·수익권이 방해됨으로써 甲중중에 재산상 손해가 발생하였다는 이유로 차임상당 손해배상액의 지급을 구하는 소(이하 '이 사건 소'라 한다)를 제기하였다. (다음 각 물음은 독립적임)

(1) 甲중중은 2020.8.17. 이 사건 소를 제기하면서 소장에 대표자 표시를 누락하였다가 제1심법원의 석명준비명령에 따라 甲중중의 대표자를 A로 기재된 서면을 제출하였다. 그러나 이 사건 소제기 당시 甲중중의 대표자는 A가 아니라 B이었다. 甲중중은 2022.10.19. 항소심법원에 甲중중의 대표자를 A에서 B로 정정하는 당사자표시정정신청서를 제출하면서 A의 기존 소송행위를 추인하는 취지라고 주장하였다. 甲중중과 乙 모두 항소심에 이르기까지 B의 대표자 자격에 관하여 다툼 적은 없고, 그에 관하여 주장하거나 증명을 하지도 않았다. 이에 대하여 항소심법원은 B에게 적법한 대표권이 있는지를 의심할만한 사정이 있음에도 B에게 당사자표시정정신청서 제출 당시에도 추인을 할 수 있는 대표권이 있었다고 볼 증거가 부족하고, 당사자표시정정신청만으로 추인을 인정하기도 어렵다는 것을 이유로, 이 사건 소가 대표권 없는 사람에 의하여 제기된 것으로 보아 부적법하다고 하여 소각하판결을 선고하였다. 이와 같은 항소심법원의 판단에 잘못이 없는지를 그 논거와 함께 설명하시오. (10점)

*** 민사소송법 5월 최근 민사소송법 판례특강 자료 90페이지 적중 출제**

대법원 2022. 4. 14. 선고 2021다276973 판결 사안을 출제한 것임

[1] 중중이 당사자인 사건에서 이미 제출된 자료에 따라 중중의 대표자에게 적법한 대표권이 있는지를 의심할 만한 사정이 있는 경우, 법원이 이에 관하여 심리·조사할 의무가 있는지 여부(적극)

[2] 법률상 사항에 관한 법원의 석명 또는 지적의무

[3] 갑 중중이 을을 상대로 소를 제기하면서 소장에 대표자 표시를 누락하였다가 제1심법원의 석명준비명령에 따라 대표자를 병으로 기재한 서면을 제출하였으나, 소제기 당시 갑 중중의 대표자는 병이 아니라 정이었고, 그 후 갑 중중이 원심법원에 대표자를 병에서 정으로 정정하는 당사자표시정정신청서를 제출하면서 병의 기존 소송행위를 추인하는 취지라고 주장한 사안에서, 정에게 적법한 대표권이 있는지에 관하여 석명권을 행사하는 등의 조치를 취하지 않은 채 소를 각하한 원심판결에 석명의무를 다하지 아니한 잘못이 있다고 한 사례

(2) 제1심법원은 청구기각판결을 하였고, 이에 대하여 甲중중이 항소하였다. 항소심법원은 甲중중이 제출한 증거들만으로는 甲중중이 X토지를 현실적으로 사용·수익하여 왔다거나, 이후 甲중중이 주장하는 乙의 불법행위로 인하여 X토지에 관한 甲중중의 사용·수익권이 방해받음으로써 甲중중에 재산상 손해가 실제로 발생하였다고 보기는 어렵다고 판단하였다. 그럼에도 항소심법원은 甲중중의 이 사건 청구를 기각하지 않고 이 사건 소가 甲중중의 중중총회결의 없이 제기되었음을 이유로 부적법하다고 보아 이를 각하하였다. 이에 대하여 甲중중만 상고하였다. 甲중중은 항소심변론종결 이후 상고심에 이르기까지 “甲중중이 중중원들의 소재를 파악하기 위한 가능한 노력을 기울인 끝에 국내에 거주하고 소재가 분명하여 통지가 가능한 중중원들에게 개별적으로 소집통지를 한 후 2023.3.24. 임시총회를 개최하였고, 위 임시총회에서 A나 B가 甲중중의 대표자로서 기존에 이 사건 소에 관하여 한 소송행위를 추진하기로 결의하였다.”라는 취지로 주장하면서 이에 부합하는 참고자료를 제출하였다. 이러한 경우 상고심법원은 어떠한 판결을 하여야 하는지를 그 논거와 함께 설명하시오. (10점)

***3·4월 민 일 민소법 “GS 강의” 및 “병합소송과 상소 특강” 중 강조한 내용**

소각하판결에 있어 소송요건의 구비 여부는 사실심변론종결 당시를 기준으로 하므로, 원심의 소각하판결은 정당하지만, 이로써 파기환송을 한다 하여도 청구기각판결을 받을 것이 명백한 경우 상고심법원의 판결은 어떠하여야 하는지에 대하여 견해가 대립하지만, 항소기각판결을 하여야 한다는 것이 불이익변경금지원칙과 관련한 대법원 판례의 태도임을 묻는 문제이다.

【문제 - 3】

甲은 2022.8.18. 乙에게 1억 원을 이자는 월 1%, 변제기는 2022.10.17.로 정하여 대여하기로 약정하였다. 乙은 2022.10.17. 갑에게 위 대여금의 이자로 2백만 원을 지급하였다. 또한 乙은 甲 소유의 X부동산을 점유하고 있다가 乙명의로 소유권이전등기를 하였다. (다음 각 물음은 독립적임)

- (1) 甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 이에 대하여 제1심법원은 乙의 변제항변을 일부 받아들여 甲의 청구 중 6천만 원을 인용하였다. 이에 甲만 항소하였는데, 乙이 甲에 대하여 가지고 있는 6천만 원의 매매대금채권을 자동채권으로 상계항변을 하였다. 이에 대하여 항소심법원은 乙의 변제항변은 전부 이유 없고 오히려 乙이 제출한 상계항변이 전부 이유 있는 것을 인정하여 甲의 청구 중 4천만 원을 인용하였다. 이와 같은 항소심법원의 판단에 잘못이 없는지를 그 논거와 함께 설명하시오. (10점)

4월 민 일 민소법 “GS 강의” 7회차 문제 완전 적중 출제

* 불이익변경금지원칙과 관련하여 GS 모의고사 문제가 사실상 완전히 동일하게 출제되었다.

【문제 - 1】

A회사는 2020. 3. 2.부터 B회사와 원단 공급계약을 체결하고 B회사에 원단을 납품하여 왔다. A회사가 B회사에 대금지급을 독촉하자, B회사는 그 동안의 거래대금을 지급하였을 뿐만 아니라 A회사가 흠 있는 원단을 공급함으로써 막대한 손해를 보았다고 주장하고 있다. 이에 A회사는 B회사를 상대로 원단 대금 1억 원의 지급을 구하는 물품대금청구의 소를 제기하였다. B회사는 소장을 송달받고 변론기일에 출석하여 A회사가 청구하는 원단 대금 1억 원을 모두 변제하였다고 주장하였다. 제1심 법원은 B회사의 변제항변을 일부(6,000만 원) 받아들여 A회사의 청구는 4,000만 원만 인용되었고 제1심 법원의 판결서 정본은 2021. 6. 10. 각 당사자에게 모두 송달되었다. 이에 A회사는 2021. 6. 16. 항소하였으나 B회사는 항소하지 않았다.

- (2) 피고 B회사는 항소심에서도 여전히 전액을 변제하였다고 주장하고, 추가로 A회사에 대한 손해배상채권 1억 원을 자동채권으로 상계항변한다고 주장하였다.

(가) 항소심 심리 결과 A회사가 주장하는 원단대금채권 1억 원이 모두 변제된 것으로 밝혀졌다면 항소심은 어떠한 판단을 하여야 하는가. (10점)

- (3) 이후 피고 B회사는 2021. 6. 26. ‘항소장’이라는 명칭의 서면을 제출하면서, ‘항소취지’란에 ‘제1심판결 중 피고 패소 부분을 취소한다.’라고 기재하였다. 이후 피고는 2021. 8. 31. ‘항소이유서’를 제출함으로써 원고 A회사의 청구를 전부 기각하는 판결을 구하는 취지를 명확히 하였고, 피고가 제출한 각 서면은 원고에게 적법하게 송달되었으며, 이에 원고 A회사는 특별히 이의를 제기하지 않은 채 변론이 종결되었다. 이에 항소심 법원은 6,000만 원 부분의 원고 A의 항소를 기각하고, 피고 B의 신청을 받아들여 제1심 판결 중 피고 B

회사의 패소 부분 즉, 4,000만 원 부분에 대하여는 제1심 판결을 취소하고 원고 청구기각의 판결을 선고하였다. 항소심 법원의 판결은 적법한가. (10점)

(2) 甲은 乙을 상대로 1억 원의 대여금의 지급을 구하는 소를 제기하여 5천만 원의 일부승소판결을 받았고, 甲과 乙 쌍방이 항소하였다. 甲은 항소심의 변론기일 전달에 법원에 소취하서를 제출하였으며, 乙은 甲의 소취하에 동의하였다. 甲은 변론기일에 출석하여 착오로 소취하가 이루어진 것이니 소취하는 무효이고, 만일 소취하가 유효하다면 착오를 이유로 소취하를 취소 또는 철회한다고 주장하면서 법원에 기일지정신청을 하였다. 이에 대하여 법원은 어떠한 조치를 하여야 하는지를 그 논거와 함께 설명하시오. (10점)

4월 민 일 민소법 “GS 강의” 7회차 문제 완전 적중 출제

* 착오에 의한 소취하와 관련하여 GS 모의고사 문제가 출제되었다.

【문제 - 2】

(5) 원고 甲은 A주택과 B주택에 대한 이 사건 소에 관하여 A를 소송대리인으로 선임하였고, A에게 상소제기 및 소취하 등에 관한 일체의 특별수권을 한 바 있었다. 이에 A는 원고 甲의 소송대리인으로 소송을 수행하던 중, 원고 甲이 이 사건 청구들 중 B주택에 관한 부분은 문제삼지 않기로 하고, 소송대리인 A에게 소취하를 해 줄 것을 요구하였다. 이에 소송대리인 A는 자신의 사무실에 근무하던 사무원 B에게 ‘甲의 소를 취하하는 내용의 소취하서를 법원에 제출할 것’을 이야기하였으나, 사무원 B는 A주택과 B주택 모두에 대한 소취하서를 제출하라는 이야기로 잘못 알고 A주택과 B주택 모두에 대한 소취하서를 법원에 제출하였다. 이에 원고 甲이 자신은 B주택에만 소취하를 해줄 것을 요청하였을 뿐 A주택에 대한 소취하 요구는 없었음을 들어 A에게 항의하였고, 소송대리인 A는 甲의 소취하서는 사무원 B의 착오에 의하여 제출된 것임을 들어 법원에 기일지정신청을 하였다. 소송대리인 A의 주장은 받아들여질 수 있는가. (10점)

(3) 甲은 X부동산에 대하여 乙을 상대로 소유권에 기한 이전등기말소청구의 소를 제기하였다. 이에 乙은 甲이 주장하는 소유권을 시인하였다. 이에 대하여 법원은 어떠한 판단을 하여야 하는지를 그 논거와 함께 설명하시오. (10점)

* 선결적 법률관계에 대한 권리자백의 문제로, 수험생 누구나 쉽게 풀었을 기초적인 문제이다.

【문제 - 4】

甲은 서울 중구 소재 지상에 위치한 지하 8층, 지상 14층 규모의 집합건물인 X상가의 구분 소유자들로 구성된 관리단(상가변영회)이다. 乙은 이 사건 상가의 구분점포의 구분소유자이고, 2017.9.1.부터 이 사건 점포에서 커피숍을 운영하고 있다. 乙은 2019.6.30.부터 관리비를 지급하지 않고 있다. (다음 각 물음은 독립적임)

(1) 甲은 2021.7.30. 乙을 상대로 상가관리비 등의 지급을 구하는 민사조정을 신청하였다. 2021.10.8. 그 조정신청서 부분이 乙의 주소 (이하 ‘이 사건 주소’라 한다)로 송달되었고, 이를 乙이 수령하였다. 乙은 2021.11.12. 제2차 조정기일에 출석하였으나 조정이 불성립되었고 조정이 성립되지 않은 것으로 사건이 종결된 후 乙의 주소가 변경되었다. 그럼에도 乙이 조정법원에 주소변경신고를 하지 않은 상태에서 민사조정법 (제36조 제1항 제2호)에 따라 2022.6.3. 청구취지 및 원인변경신청서를 각 이 사건 주소로 우편송달(통상송달)을 실시하였으나 ‘수취인불명’으로 乙에게 송달되지 아니하자, 2022.6.14. 위 변론기일통지서와 청구취지 및 원인변경신청서를 등기우편의 방식으로 각 발송송달을 실시하였다. 2022.6.20. 판결 선고기일통지서를 이 사건 주소로 우편송달(통상송달)을 실시하였으나 ‘수취인불명’으로 乙에게 송달되지 아니하자, 2022.7.4. 위 판결선고기일통지서를 등기우편의 방식으로 발송송달을 실시하였다. 제1심법원은 2022.7.8. 甲 승소판결을 선고하고 그 판결정본을 2022.7.12. 이 사건 주소로 우편송달을 실시하였으나 ‘수취인불명’으로 송달되지 아니하자 2022.7.25. 공시송달의 방법으로 위 판결정본을 송달하여 2022.8.9. 그 송달의 효력이 생기게 되었다. 乙은 2023.1.9.에 이르러서야 제1심 판결정본을 송달받지 못하여 항소기간을 준수하지 못하였다는 이유로 추완항소장을 제1심법원에 제출하였다. 이에 대하여 항소심법원은 이 사건 추후보완항소가 허용되지 않는다고 판단하였다. 이와 같은 항소심법원의 판단에 잘못이 없는지를 그 논거와 함께 설명하시오. (10점)

* 민일 민사소송법 기본서 841면의 공시송달과 추후보완항소에 대한 판례 전면 출제

판례

● 기본태도

송달받을 사람이 송달사실을 모르며, 모르는 데에 과실이 없어야 추후보완이 인정될 수 있으며, 원고의 공시송달신청시 원고에게 과실이 존재하였는지 여부는 추후보완의 허부에 있어서 고려 대상이 아니다(1987.9.22. 87므8).

● 처음 소장부분 송달부터 공시송달로 소송이 진행된 경우 — 추후보완허용

「소장부분과 판결정본 등이 공시송달의 방법에 의하여 송달되었다면 특별한 사정이 없는 한 피고는 과실 없이 그 판결의 송달을 알지 못한 것(2000.9.5. 2000므87)」이어서 추후보완이 허용된다.

● 조정이 성립되지 아니한 것으로 사건이 종결된 후 피신청인 주소가 변경되었는데도 주소변경신고를 하지 않은 상태에서 조정이 소송으로 이행되어 변론기일통지서 등 소송서류가 발송송달이나 공시송달의 방법으로 송달된 경우

조정이 성립되지 아니한 것으로 사건이 종결된 후 피신청인의 주소가 변경되었음에도 피신청인이 조정법원에 주소변경신고를 하지 않은 상태에서 민사조정법 제36조 제1항 제2호에 따라 조정이 소송으로 이행되었는데, 통상의 방법으로 변론기일통지서 등 소송서류를 송달할 수 없게 되어 발송송달이나 공시송달의 방법으로 송달한 경우에는 처음부터 소장 부분이 적법하게 송달된 경우와 달라서 피신청인에게 소송의 진행상황을 조사할 의무가 있다고 할 수 없다. 따라서 피신청인이 이러한 소송의 진행상황을 조사하지 않아 상소제기의 불변기간을 지키지 못하였다면 이는 당사자가 책임질 수 없는 사유로 말미암은 것에 해당한다(대법원 2015.8.13. 선고 2015다213322 판결).

● 통상의 송달방식으로 소송이 진행되던 중 송달이 차후 공시송달로 바뀐 경우

(1) 추후보완 불허

「소송의 진행 도중 소송서류의 송달이 불가능하게 된 결과 부득이 공시송달의 방법에 의하게 된 경우에는 처음부터 공시송달의 방법에 의한 경우와는 달라서 당사자에게 소송의 진행 상황을 조사할 의무가 있는 것이므로, 당사자가 법원에 소송의 진행 상황을 알아보지 않았다면 과실이 없다고 할 수 없으며, 또한 이러한 의무는 당사자가 변론기일에서 출석하여 변론을 하였는지 여부, 출석한 변론기일에서 다음 변론기일의 고지를 받았는지 여부나, 소송대리인을 선임한 바 있는지 여부를 불문하고 부담하는 것이다(1998.10.2. 97다50152).

(2) 甲은 2021.9.27. 乙을 상대로 상가관리비 등의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 제1심법원은 2021.10.11. 이행권고결정을 하였고, 乙은 2021.10.18. 소장에 기재된 乙 주소지에서 이행권고결정서 등본을 송달받고 2021.10.19. 제1심법원에 답변서를 제출하였다. 乙은 2021.10.20. A교도소에 구속수감되었다. 제1심법원은 2021.11.16.과 2021.12.14. 두 차례 변론기일을 열고 변론을 종결하였는데, 변론기일통지서 등을 乙 주소지에 폐문부재로 송달하지 못하여 발송송달 방법으로 송달하였고, 乙은 변론기일에 출석하지 않았다. 제1심법원은 제1심법원은 2022.1.11. 甲의 청구를 인용하는 판결을 선고하였고, 판결정본을 乙 주소지에 폐문부재로 송달하지 못하여 재판장의 공시송달명령에 따라 공시송달 방법으로 송달하였고, 2022.2.10. 0시에 송달의 효력이 발생하였다. 乙은 2022.8.19. A교도소에서 출소하여 2022.8.22. 제1심 판결정본을 발급받고 2022.9.2. 제1심법원에 추완항소장을 제출하였다. 이에 대하여 항소심은 이 사건 추완항소를 부적법하다고 보아 각하하였다. 이와 같은 항소심

법원의 판단에 잘못이 없는지를 그 논거와 함께 설명하시오. (10점)

*** 민사소송법 5월 최근 민사소송법 판례특강 자료 143페이지 이하 별표 6개짜리 적중 출제**

* 최근 판례 강의 중 상당히 중요한 판례라 했던 아래 판례의 사실관계를 토대로 그대로 만든 문제이다. 강의자료 및 강의 중 별표를 사실상 6개 이상을 그려넣었을 정도로 중요한 판례임을 강조한 바 있다.

*** 해 결**

1. 이행권고결정등본을 주소지 송달받은 바 있으므로, 이후 장소변경신고 불이행에 의한 발송송달로서의 요건이 충족되었는지가 먼저 문제되는 바, 교도소 수감 중인 자는 장소변경신고의무를 부담하지 않는다는 것이 판례임 ➡ 발송송달 부적법
2. 판결선고 이후 판결서의 공시송달 - 재판장의 명령에 의한 것이므로 설령 공시송달의 요건에 흠이 있어도 유효라는 것이 판례임 ➡ 그러나, 공시송달의 요건은 결여됨
3. 송달장소변경신고의무도 없고, 공시송달에도 하자가 있다면 불귀책사유를 인정할 수 있음

*** 당시 자료 그대로 옮김**

● 소송 중 수감 및 위법한 공시송달과 추후보완 ★★★★★★

당사자가 소송 계속 중에 수감되었으나 법원이 판결정본을 민사소송법 제182조에 따라 교도소장 등에게 송달하지 않고 당사자 주소 등에 공시송달 방법으로 송달한 경우, 송달의 효력이 있는지 여부(적극) / 이 경우 수감된 당사자가 책임을 질 수 없는 사유로 불변기간을 준수할 수 없었던 때에 해당하여 그 사유가 없어진 후 2주일 내에 추완 상소를 할 수 있는지 여부(원칙적 적극) 및 여기에서 ‘사유가 없어진 때’의 의미 (대법원 2022. 1. 13. 선고 2019다220618 판결)

【판결요지】

당사자가 소송 계속 중에 수감된 경우 법원이 판결정본을 민사소송법 제182조에 따라 교도소장 등에게 송달하지 않고 당사자 주소 등에 공시송달 방법으로 송달하였다면, 공시송달의 요건을 갖추지 못한 하자가 있다고 하더라도 재판장의 명령에 따라 공시송달을 한 이상 송달의 효력은 있다.

수감된 당사자는 민사소송법 제185조에서 정한 송달장소 변경의 신고의무를 부담하지 않고 요건을 갖추지 못한 공시송달로 상소기간을 지키지 못하게 되었으므로 특별한 사정이 없는 한 과실 없이 판결의 송달을 알지 못한 것이고, 이러한 경우 책임을 질 수 없는 사유로 불변기간을 준수할 수 없었던 때에 해당하여 그 사유가 없어진 후 2주일 내에 추완 상소를 할 수 있다. 여기에서 ‘사유가 없어진 때’란 당사자나 소송대리인이 판결이 있었고 판결이 공시송달 방법으로 송달된 사실을 안 때를 가리킨다. 통상의 경우에는 당사자나 소송대리인이 사건 기록을 열람하거나 새로 판결정본을 영수한 때에 비로소 판결이 공시송달 방법으로 송달된 사실을 알게 되었다고 보아야 한다.

